

1501554-02.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... em ponto conhecido como local de tráfico de drogas e, ainda, que ele apresentou comportamento suspeito quando notou a aproximação policial.

O E. Tribunal de Justiça, inclusive, já reconheceu estes como justos motivos para realização de abordagem policial, confira-se:

"Tráfico de Drogas - Preliminar que requer o reconhecimento da nulidade da abordagem e revista pessoal - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501554-02.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501554-02.2021.8.26.0537 2021/001309

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO DOUGLAS FÉLIX MARINHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

PEDRO DOUGLAS FÉLIX MARINHO, qualificado a fl. 21, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 11h00, na Passagem Tião Carreiro, altura do nº 30, Vila Nogueira, nesta cidade e Comarca de Diadema, tinha em depósito para fins de mercancia e entrega à terceiros, 25 porções de "crack", com peso de 5g., 32 porções de cocaína, pesando 20,06g., e 10 porções de maconha, com peso de 5,6g., substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Dispensada audiência de custódia, em razão da Pandemia de COVID-19, com base do comunicado da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo editado em 17/03/2020, proferiu-se decisão convertendo a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva (fls. 55/58).

O réu foi notificado (fls. 116) e apresentou defesa prévia às fls. 117/119.

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2021 (fl. 120).

O réu foi citado (fl. 151).

Realizou-se, nesta data, audiência de instrução e julgamento, de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foram

ouvidas duas testemunhas policiais e interrogou-se o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes.

Em alegações finais, a D. Promotora de Justiça requereu procedência do pedido, condenando-se o réu nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, pleiteou o aumento da pena-base em razão de um dos entorpecentes ser "crack", que tem maior poder viciante. Na segunda etapa, requereu o agravamento da pena pela reincidência específica e, caso seja utilizada a confissão extrajudicial, que seja compensada com a agravante; o afastamento do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, com a fixação do regime inicial fechado.

A D. Defesa, por sua vez, preliminarmente requereu a declaração de nulidade de todos os atos do processo desde a realização da abordagem do réu, tendo em vista que não havia fundada suspeita para que ele fosse abordado, pois a testemunha policial disse que ele somente foi abordado porque estava nervoso, o que configuraria abuso de autoridade e nulidade. Sustentou, ademais, que o réu não foi preso em poder dos entorpecentes, que estava em lugar distinto e que a testemunha policial afirmou que o réu ainda iniciaria a prática do tráfico, não tendo ultrapassado a fase dos atos preparatórios, inclusive porque não há prova de que os entorpecentes estivessem em sua posse. Assim, requereu a absolvição do réu, tendo em vista que ele não teria praticado o crime. Subsidiariamente, sustentou que o réu não foi visto traficando e não é crível que o réu tivesse indicado, de livre e espontânea vontade que estivesse traficando, e os elementos trazidos durante a instrução não teriam comprovado a prática do tráfico. O réu é trabalhador informal, que estava trabalhando em feira-livre, não sendo possível trazer em juízo prova desse trabalho. Por tais razões, requereu a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, incisos II ou VII. Pena no mínimo legal, com regime prisional diverso do fechado, revogando-se a prisão preventiva e estabelecendo-se a prisão domiciliar, pois o réu é portador de tuberculose e a situação de pandemia e do contágio global por cepas de gripe o colocaria em situação de risco.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais.

A preliminar de nulidade da abordagem e, em consequência, de todos os atos subsequentes não prospera.

Em sede inquisitiva, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu informaram que ele estava em ponto de traficância, tendo apresentado atitude suspeita ao visualizar a guarnição (fls. 05/06). Em Juízo, como se verá adiante, as testemunhas narraram novamente que a abordagem e revista foi motivada pelo fato do réu estar parado em ponto conhecido como local de tráfico de drogas e, ainda, que ele apresentou comportamento suspeito quando notou a aproximação policial.

O E. Tribunal de Justiça, inclusive, já reconheceu estes como justos motivos para realização de abordagem policial, confira-se:

"Tráfico de Drogas - Preliminar que requer o reconhecimento da nulidade da abordagem e revista pessoal - Inocorrência - Fundada suspeita bem evidenciada - Comportamento do réu, já conhecido no meio policial, que se encontrava em local escuro e sabido ponto de mercancia de drogas e que, ao avistar a aproximação policial, tentou se evadir - Prova certa - Exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis - Maus antecedentes - Reincidência bem caracterizada - Regime fechado necessário ante a gravidade concreta do delito."

(TJSP; Apelação Criminal nº 1500082-78.2020.8.26.0608; Relator Des. André Carvalho e Silva de Almeida; 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021).

Note-se que a própria defesa, em seus memoriais, admitiu que era crível que o réu apresentasse comportamento suspeito quando visualizou a polícia, pois ele sabia que era foragido em outro Estado da Federação, o que corrobora a afirmação dos policiais, no sentido de que o comportamento do réu foi diferenciado e justificou a abordagem realizada, especialmente considerando que a atitude dele somou-se ao fato de estar em lugar onde sabidamente se costuma praticar o tráfico de drogas.

Logo, nada havendo de irregular, afasto a tese de nulidade da abordagem policial.

Na mesma esteira, não há que se falar na prática, pelo réu, de meros atos preparatórios ao tráfico, ou, ainda, crime tentado, pois o simples fato dele ter em

depósito a droga já foi suficiente para configurar a prática do tráfico de entorpecentes, de forma que não era necessário que iniciasse a comercialização, bastando que tivesse a droga à sua disposição para entrega a consumo de terceiros, tal como foi flagrado.

Desta maneira, afasto a tese de atipicidade da conduta.

Ausentes, no mais, nulidades a sanar ou outras preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 08/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), das fotografias dos entorpecentes (fls. 15/17), do laudo de constatação (fls. 18/20), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/99) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Ao ser interrogado em sede policial, o réu confessou a prática do tráfico de entorpecentes. Disse que "foi contratado por uma pessoa desconhecida para comercializar drogas no local, sendo que iria ganhar 15% do valor recebido das vendas dos entorpecentes, contudo, não havia iniciado seu turno. Por fim, confessou que já fora preso pelo mesmo tipo penal no Estado do Pernambuco, sendo que, inclusive, se encontra evadido do sistema prisional." (fl. 07).

Interrogado em Juízo, o réu NEGOU a veracidade dos fatos narrados na denúncia. Disse que estava trabalhando e, por volta das 11h00, foi comprar um "pó" para cheirar, quando a polícia chegou e o enquadrou. O policial lhe fez perguntas, inclusive se era usuário de drogas, perguntou se tinha passagem policial, tendo respondido positivamente. Pegou os seus vinte reais e depois o levou preso. Estava foragido e veio para São Paulo para mudar sua vida, estava trabalhando. Nesta cidade de Diadema, estava residindo na "Favela do Pantanal", na Rua Primavera. Na Viela Bahia era onde morava, mas quando foi preso estava morando na Rua Primavera. A feira em que estava trabalhando fica na "Praça do Marilene", no Bairro Vila Nogueira, o local onde foi preso é próximo, cerca de cinco minutos a pé. Não confessou em sede policial. Ficou em silêncio e assinou uns papéis que lhe mandaram assinar, mas não chegou a ler o que estava assinando, pois estava transtornado, falando que não era o traficante. Não conhecia os policiais que o prenderam, antes dos fatos. Os policiais procuraram pelo seu nome e lá constou que era foragido da polícia, mas em nenhum momento disse a eles que era foragido. Porém, logo depois disse que afirmou aos policiais que tinha passagem anterior e foi por isso que o conduziram à delegacia. O policial não acompanhou seu depoimento em sede policial, até porque não falou nada em sede policial.

Tal versão, entretanto, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova, que se revelaram suficientes para demonstrar a prática do crime pelo réu, nos termos da confissão prestada em sede policial.

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este juízo, a testemunha Ana Cláudia de Barros Dias, policial civil, afirmou que estava realizando diligência por local conhecido com o ponto de realização de tráfico de entorpecentes, quando avistou o réu em atitude suspeita: ele estava sozinho a apresentou estranheza ao ver a equipe, tendo realizado a abordagem a ele. O réu trazia consigo dinheiro trocado e, indagado sobre o que ali fazia, ele disse que havia começado naquele dia e que era seu primeiro dia, pois teria sido contratado por indivíduo desconhecido para traficar no local; porém, não havia começado "o turno", não tendo ficado claro se a quantia de vinte reais com ele localizada seria proveniente do tráfico ou não. A sacolinha com as drogas estava embaixo de um saco de entulho, pelo réu indicada; na sacolinha havia maconha, "crack" e cocaína. Não conhecia o réu antes dos fatos e, ao que sabe, fazia pouco tempo que ele estava neste Estado, pois era procurado em outro pelo tráfico de entorpecentes. Às perguntas da D.; Defesa, respondeu que o réu estava sozinho, que com ele não havia nenhum entorpecente, tendo ele mostrado o local onde as drogas estavam, lugar este que não seria encontrado pela equipe se não fosse mostrado pelo réu. O réu confessou informalmente a prática do tráfico e mostrou o lugar onde estava escondida a droga; disse que ganharia 15% do valor da

venda. Não havia anotações ou rádio comunicador no local. Havia 32 porções de cocaína, 25 de "crack" e 10 de maconha. Com relação ao dinheiro, era vinte reais em dinheiro trocado, em diversas notinhas, não se recordando quais eram seus valores. No mesmo sentido, a testemunha Cleber Matias de Oliveira, também policial civil, narrou os fatos à semelhança de sua colega, confirmando, dentre outras coisas, que foi ao local dos fatos com sua parceira de equipe, onde localizaram o réu com vinte reais no bolso e, em seguida, ele indicou onde estava a sacola de entorpecentes, escondida embaixo de sacos de entulho. Na sacola havia porções de "crack", cocaína e maconha. Já na delegacia, o réu confessou que ganharia 15% do valor da venda das drogas e que estava procurado em outro Estado. Não conhecia o réu antes dos fatos. Às perguntas da D. Defesa, respondeu que é de conhecimento da equipe que o exato local onde o réu estava é ponto de tráfico e ele foi abordado justamente porque estava neste local. O réu confessou o que estava fazendo no local logo após ser indagado, o fez de livre e espontânea vontade. Na rua o réu confessou que estaria no local traficando, já na delegacia que ele acrescentou que auferiria os 15% da venda e que era procurado. Acompanhou o depoimento do réu na delegacia. Havia vinte reais em poder do réu. Não havia anotações, apenas o dinheiro. No local o tráfico costuma ser praticado pelo vapor (aquele que vende), o qual deixa um olheiro para avisar a chegada da polícia. No caso do réu não havia um olheiro. Isso também é costume dos traficantes, que o fazem para ganhar mais.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências que, como já mencionado, deram-se de forma escurreita. Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocentes. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada.

Por outro lado, a significativa quantidade de droga apreendida em poder do réu (25 porções de "crack", com peso de 5g., 32 porções de cocaína, pesando 20,06g., e 10 porções de maconha, com peso de 5,6g.) e as circunstâncias em que se deu sua prisão (o réu estava em local conhecido como ponto de tráfico, apresentou comportamento suspeito ao notar a aproximação dos policiais e a eles indicou o lugar em que estavam escondidas as drogas acima indicadas), evidenciam que, efetivamente, os estupefacientes apreendidos pertenciam a ele e se destinavam à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Convém ainda pontuar que a versão trazida pelo réu em juízo é totalmente descolada da realidade, pois se verdadeira fosse, teria sido apresentada desde o começo, ainda em sede policial. Porém, como já dito, ele confessou a prática do tráfico na polícia e, somente em sede judicial, entendendo ser mais conveniente, negou a prática dos fatos.

Ademais, não se pode desconsiderar que o réu morava em região distinta da cidade e não justificou sua presença em outro bairro, longe de sua casa, pois não comprovou que estivesse trabalhando próximo ao local dos fatos.

O réu poderia ter trazido aos autos declaração do feirante que lhe deu trabalho ou, ainda, de outros colegas da barraca que o tivessem visto trabalhando naquele dia e local, mas não o fez. Ao contrário, o réu sustentou que estava trabalhando na feira livre, mas foi preso a mais de meio quilometro do local de sua realização, parado, sozinho, supostamente a espera de um traficante para vender-lhe cocaína, causando estranheza que ele soubesse onde há ponto de tráfico naquele local que frequentava apenas a trabalho, especialmente por ter chegado neste Estado de São Paulo há pouco tempo, como mencionou em audiência.

Sobre o local de realização das feiras livres em Diadema e a distância entre a feira do bairro Vila Nogueira e o ponto da prisão do réu confira-se:

<http://www.diadema.sp.gov.br/110-cidade/conheca-diadema/9903-feiras-livres> e a indicação do trajeto, obtida no site Google Maps, por meio do seguinte link: de Passagem Tião Carreiro a Rua Salvador Corrêa de Sá - Google Maps.

Consigno, também, a existência de contradição na fala do réu em juízo, pois primeiro ele disse que havia contado aos policiais que tinha passagem policial anterior; depois, ele disse que os policiais descobriram a passagem criminal apenas quando consultaram seu nome; por fim, ele se retratou e disse que desde logo informou aos policiais que tinha a antiga condenação.

Assim, enquanto a negativa judicial do réu ficou isolada nos autos e desacreditada, a confissão apresentada prestada em sede policial encontrou amparo sólido nos depoimentos das testemunhas policiais, tornando-se suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico. Em face dessas circunstâncias, impossível a absolvição por insuficiência de provas.

Ressalto, ainda, que a condição de viciado do réu não ficou comprovada nos autos e que a mera alegação de que é usuário não é suficiente para excluir a prática do crime, pois é sabido que usuários de drogas acabam se envolvendo com o tráfico com a finalidade de sustentar o próprio vício. Frise-se, ainda, que a quantidade de droga encontrada em poder do réu é suficiente para afastar a possibilidade de que se tratasse de substância para consumo pessoal.

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fl. 148). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Consigno que, em que pese o requerimento do Ministério Público, entendo não ser o caso de aumentar a pena nesta fase em razão da apreensão de "crack" em poder do réu, pois, apesar de se tratar de entorpecente com maior poder vulnerante, a quantidade apreendida não destoa da média do que normalmente é localizado nesta Comarca.

Na segunda fase, verifico presente a circunstância agravante da reincidência, específica pelo crime de tráfico de entorpecentes (conforme certidão de objeto e pé de fl. 178, referente aos autos nº 0004992-71.2015.8.17.0990, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda-PE, com trânsito em julgado em 14/08/2017) e, lado outro, a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea em sede inquisitiva, já que esta foi utilizada para, somando-se às outras provas, embasar a condenação. Assim, compenso uma circunstância com a outra, em razão do caráter preponderante das duas, mantendo a pena inalterada neste momento.

Na derradeira etapa, deixo de reduzir a pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas com o réu (quase setenta porções ao total) e, especialmente, porque o réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Logo, não preenche o requisito objetivo para a concessão desse benefício.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime inicial FECHADO, o qual se justifica, além da quantidade de pena, também pelo fato do réu ser reincidente específico, já tendo sido condenado pela mesma conduta e tendo praticado este novo crime após ter se evadido do sistema penitenciário. Logo, tudo indica que a fixação de regime mais brando não seria suficiente a impedir que ele tornasse a delinquir.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se

possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu PEDRO DOUGLAS FÉLIX MARINHO à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista os redimentos declarados pelo réu, que se encontrava desempregado antes de ser preso.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Com relação ao valor apreendido (fls. 12/13), decreto seu perdimento em favor da União. Preceda-se conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas. Publique-se, intime-se e façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA